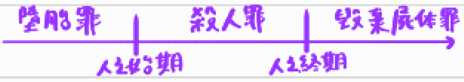
壹、生命法益絕对保护原則



畸產兒

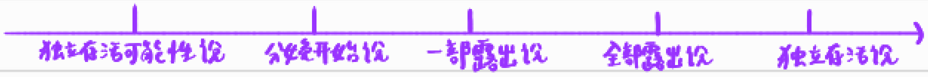
一、生命法益无価値高低之区分，人之生命不論其成熟度或有无独立生存之能力，均為刑法所保护 ⇒刑法上无所謂无価値之生命

二、被害人承诺

1、刑法承认之超法規阻卻違法事由

2、通說：個人对自己之生命法益无自由处分之权利 ⇒§275Ⅰ

貳、人之始期



一、人与胎兒區別実益 <人：殺人罪
胎兒：墮胎罪

二、独立呼吸說：民法採之（民§6）（SC 20上1052例）

三、全部露出說（有力說、梁恒昌）：全部露出始為人

四、一部露出說（JP判例、通、蔡墩銘）：具单独攻擊可能性，故可明確区分墮胎罪与殺人罪之客体

五、分娩开始說（陣痛开始說）（Ger通、王、澤、林山田）：陣痛（子宮收縮）时、剖腹產切开子宮时（不可逆医療行為）

1、对人之保护較周延

2、体系解釋：§274 生母殺嬰罪：「生產时或甫生產後」⇒ §274之被害人包括「生產时」之人，故人之始期应為「生產开始时」

六、独立存活可能性說：24週後，胎兒已可脫離母体，有独立存活之保护（甘）

1、优点：对其保护有較大机率使过失致死成立 + 保持与优生保健§4規定体系一致

2、批評：过早保护，使婦女亦極有可能成為潛在之犯罪人（ex：辱罵孕婦对胎兒成立公然侮辱、婦女跌倒流產成立过失致死）

參、人之終期

一、心肺功能喪失說（古典死亡定义、臨床死）：依現代医学，已非妥当（ex：CPR、葉克膜、心臟移植）

二、三徵候說（綜合判斷說）：心臟鼓动、自発性呼吸不可逆停止、瞳孔放大（甘、JP、TW通說）

1、心臟：循环、肺：呼吸、瞳孔：神經

2、現今之心肺死即為三徵候，完全取代心肺功能喪失說

3、主張腦死說可能侵害有復甦机会之人，僅於器官移植之目的下才可例外採取腦死說（林東茂、褚劍鴻、甘、黃丁全）

三、腦死說：腦功能不可逆喪失（林山田、SC95台上1692、王）

1、医界承认：腦死後，即使医療技術優越，亦无法長時間維持心跳及呼吸

2、全腦死說：大腦、小腦、腦幹皆停止功能（EU、US、CA）

↳判斷：陷入深昏迷之原因可得確定、腦功能臨床測試（深昏迷/无意识；腦幹反射功能喪失、腦電波平直 腦功能不可逆喪失）

3、腦幹死說：腦幹死即已到達生命之不可逆点（UK 1976、US 1971、TW腦死判定準則）

4、腦波停止說（蔡墩銘）

5、於医療領域中若不採腦死說，对於是否繼續治療，將处於模糊狀態

6、王：只要生命進入不可逆点，即可认定為刑法上之死亡，且此係对生命保护之擴大（不用等心肺死即可成立殺人罪）

肆、普通殺人罪 (§271)

一、外国立法例：謀殺罪、殺人罪 (Ger§211、212)

二、客观TB

1.行為主体：被害之外之任何人，以被害人=加害人⇒自殺

2.自殺不罰 (§275 加工自殺立法理由)

(1) 法理上之不便：刑法之極端，不過能令人死，自殺者既不畏死，則刑罰失其效力 (失去一般預防之效，即使放棄，亦難以保受懾於刑法)

(2) 實際上不便：自殺既遂，自无处罰餘地 (刑訴§303⑤)，則可处罰者，惟未遂者，然其適足以獎勵自殺既遂，非立法本意

(3) 故自殺不論既未遂概不加刑，惟加工則在所必罰耳

(4) 雖係非理性之自我否定行為，僅違反個人於道德与倫理上之对己義務，只能給予道德責難，不应給予刑法制裁

(5) 刑法之正当性应以個人行為对他人或社会有所侵害為限，自殺只涉及個人自我事项，未侵害他人利益，自不得处罰之

3.行為客体：行為人外之任何人，所謂人应係已出生而未死亡者

4.行為：无限制，不限以作為方式，亦可為不作為

三、主观要件

1.須具備故意 (間接or直接)

2.若使用刀槍，且朝頭、胸腔、腹腔攻擊，可认其至少具殺人之未必故意 (由客观行為証成主观意圖) (SC 44台上373例)

四、既未遂、預備

1.实害犯：出現死亡結果為既遂

2.著手但人未死，則為未遂，ex：加毒藥於食物但被發現 (SC 57台上2861例)

3.預備：有主观殺人故意並已為著手前之準備行為、对結果發生有重大性或客观上採取趨近著手階段之行為

└ex：持刀埋伏、持刀前往之途中 ⇒ 規面=无從著手=預備 (SC 32上217例)、潛伏被發覺=未实施=預備 (SC 29上2例、24上1251例)

五、競合

1.殺人前傷害：法條競合⇒排除 (通)；与殺人罪屬一行為⇒補充关係，論殺人即為已足 (林山田)

2.遺棄毀損屍体罪 (§247)

(1) 与罰後行為 (不罰之後行為)：後行為僅係前行為之伴隨行為，只处罰主要之前行為，即可吸收後行為之不法与罪責內涵，可以法條競合处理

(2) 砍斷頭部身体做為殺人之手段 視為殺人行為之一部，因行為人砍身体非屍体 (SC 28上1026例)

(3) 殺人後離開現場，法律不可能期待殺人者留在現場，更不可能期待殺人者於事後殮葬死者⇒不另成罪

(4) 殺人後，遺棄至他地，成立遺棄屍体罪 (通、高院107上訴3110)

(5) 处理屍体过程雖草率不合禮儀，但有將屍体掩埋則不構成遺棄屍体罪 (SC 108台非93)

伍、殺直系血親尊親屬罪 (§272)

一、行為主体：直系卑親屬，不論婚生、非婚生、法定、自然皆屬之

1、不純正身分犯

2、共犯、教唆犯：因此身分為加重罪責要素非不法要素 ⇒ §31Ⅱ只能適用§271 (SC 27上1338例、甘、王)

↳ 不法身分⇒加重構成要件(田) ⇒ §31Ⅰ、罪責身分⇒行為人可非難性因素遂提高⇒§31Ⅱ (甘)

二、行為客体：直系血親尊親屬

1. 包括自然血親、法定血親 (SC 37上2192例、26決议(一))

2. 收養关係終止後適用 §271

三、主观要件

1、須认识所殺之人為直系血親尊親屬 (錯误⇒所知重於所犯，從所犯原則⇒§271)

2、知被害人為直系血親尊親屬，而教唆或幫助他人加以殺害者，仍成立教唆或幫助殺直系血親尊親屬罪 (甘、王)

四、既、未遂及預備：均用§271，但均加重至$\frac{1}{2}$

陸、殺未滿7岁兒童罪 (§272-1)

一、量刑差異

1、「加重其刑二分之一」：法定刑下限加重$\frac{1}{2}$

2.「加重其刑至二分之一」：於上限度內，應加重多少，由法院自由裁量之 (SC 109台上3565)

二、行為主体：一般犯⇒所有人

三、行為客体：未滿7岁之人

四、行為

1、§272-1Ⅰ：无限制

2、§272-1Ⅱ：凌虐方式 → §10Ⅲ

五、主观構成要件：故意

1、須认识所殺之人為未滿7歩之人，认识不以直接故意為限

2、經常性、反覆性、長期性並已有升高死亡风险時，有「凌虐殺害」之間接故意

六、既、未遂与預備

1、構成殺人但未遂⇒§271Ⅱ 殺人未遂

2、構成凌虐方式⇒§272-1Ⅲ、Ⅱ

柒、义憤殺人罪（§273）

一、情狀

1、当場

(1) 被害人不正行為之際，行為人須親見（院字2093）

(2) 基於過去之事實因而引發憤怒；不滿被害人回應，始萌生殺人犯意者，均不屬之（SC 107台上4890）

(3) 不須如正当防衛般具現在性：加害行為与不正行為間有時間与空間上之緊密关連

(4) 實務常見不符正当防衛而以§273減刑

ex：男友打女兒，並脅迫其前往坐檯，父親付15万 請求分手，被害人拒絕，父親恐被害人人財兩得，憤而殺之（台南高分院95重上更(二)56）

ex：常向父.母要錢，並吸毒後毆打父，並揚言綁架外孫女，老父某天又因金錢爭執，手持鐵鎚頭殺之（台中高分院97上訴563）

2、激於义憤（SC 28上2564例）

(1) 被害人有不正行為或不义行為在先

(2) 不正行為客觀上无法容忍，足以引起公憤

(3) 任一有理性之人，在此情形下也足以被激的失去自我控制（王：标準接近正当防衛）

(4) 目睹他人对自己近親家屬實施不义行為，得主張基於义憤（高雄高分院89上更(二)377）

(5) 行為人本身必須是无責之人（自身不能為义憤之挑起者）⇒ 权利濫用、失权效（Ger§213）

3、非不正之行為（實務判決）

(1) 擅賣眾地為所不分（SC 28上2564例）

(2) 受被害人辱罵盛怒（SC 91台上3231）

(3) 向他人借錢，他人拒借而心生不快（SC 76台上5808）

(4) 見父親与他人互毆（徒手，双方均有傷人行為），持刀砍殺該他人（SC 92台上5087）

(5) 与被害人談判妻子以前与被害人之曖昧关係而生衝突（SC 82台上4809）

4. 外遇

(1) 舊實務：允許減刑（SC 33上1732例、27決议(一)）

(2) 王：不應肯认，若认可則毋寧鼓勵对於配偶外遇行為，另一方得名正言順之义憤殺人

(3) J791 通姦罪違憲，已非犯罪，僅涉及私人領域 ⇒ 不认足以引起公憤

二、競合：义憤殺害直系血親尊親屬

1. 優先適用減刑（王、田），以免刑之過苛 ⇒ §273（ex：兄見妹遭父強制性交）

2. 同樣發生於§272、§275 I 之競合

捌、生母殺嬰罪 (§274)

一、立法理由：畏羞恥而犯之，凶性与尋常殺人有別，故仿多國立法例，科以較輕之刑

二、修正：「因不得已之事由」，理由：要件嚴格限制，避免对甫出生嬰兒之生命保护流於輕率，此事由由法院審酌具体個案事实

三、Ger廢除⇒其生母得留於医院，由社会机構安排領養，殊難想像生母有殺嬰理由

四、客观構成要件

1、行為主体：身分犯，限生母，若与生父共同殺之⇒生父成立§271 (§31Ⅱ)

2、行為客体：所生子女(不論婚生、非婚生)，並產出之嬰兒須活產或具生存可能性

3、行為時点：生產時或甫生產後

(1) 生產時：「生產过程」中，即已有生產徵候(羊水流出、胎衣破裂、陣痛)⇒人之始期应採陣痛说

(2) 甫生產後：緊接生產後，尚未开始撫育(未开始餵奶)(褚劍鴻)⇒出生後五日不屬之 (SC 28上2240例)

↳蔡聖偉：以婦女是否仍处不穩定情緒為斷

4、不得已之事由：遭性侵受孕、嬰兒有難以治療之疾病、年齡太小即生子(13岁)⇒立法理由：年齡、背景、經濟綜合判斷之

五、主观要件：故意犯

1、須对所殺之人為自己甫生產之子女有认识

2、主观上有，卻誤殺他人之子女殺之⇒§271

六、未遂罰之

七、競合

1、实害犯：以嬰兒死亡結果為必要

2、若不忍殺死而改以遺棄(立法未考量)

(1) 实害犯处罰>危險犯⇒殺嬰(实害)<危險不合原則

(2) 危險犯与实害犯有補充关係⇒適用§274即為已足，排斥§293Ⅱ前 (王、田)

八、有学说认為此係個人特殊之減輕罪責事由

玖、加工自殺罪 (§275)

一、修法：將教唆、幫助／囑託、承諾殺人分開

二、可罰性

1、囑託、承諾殺人

(1) 本質上係殺人行為 (他殺)，不同與 §275Ⅱ 自殺行為

↗適用§31Ⅰ

(2) 宣示生命法益絕對保護原則，不得以承諾阻卻違法性，但可非難性較一般殺人低，故減輕刑責 (降低R，非個人S減輕事由)

2、幫助、教唆他人自殺

(1) 本質上係自殺之從犯，但因正犯不罰，其可罰性受質疑

(2) 肯定說

A、對他人生命之特殊侵害行為 ⇒ 獨立之正犯型態，不適用總則之從犯從屬理論 (限制從屬理論)

B、與自殺行為迥異 ⇒ 性質係否定他人生命之行為，具實質違法性 (有稱「共犯的正犯化」) (甘)

C、立法理由：惟加工者在所必罰耳 ⇒ 立法者認為具獨立不法內涵

(3) 否定說

A、即使教唆，仍為「遠因」，事實上更主力之近因應為自殺者本身

B、既然自殺者係於自由意志下決定結束生命，基於自我負責，應不可將自殺歸責於教唆、幫助者 (黃常仁、田)

3、他國立法例

(1) Ger §216 僅罰承諾、囑託殺人 ⇒ 自殺行為之正犯非構成要件該當且違法之行為 ⇒ 欠缺TBR之主行為，無從成立幫助、教唆

(2) Ger §217 (2015)：營利性質之幫助自殺由不處罰改為處罰 (Ger 憲法法庭 2020：違憲)

(3) JP §202 仍罰教唆、幫助犯

三、囑託、承諾殺人罪 (§275Ⅰ)

1、囑託：被害人居於主動之地位，要求他人將其殺害

2、得其承諾而殺之：由行為人主動發起，被害人居於被動地位給予承諾

↗無強制、威脅、錯誤、被欺騙

3、意思決定須出於自由意思與真意、無瑕疵、具誠摯性，且須有成熟之判別事理之能力，非出於一時沮喪，須於自殺時仍存在

4、心智成熟度不足之兒童、重度智障之人，不具有殺之囑託或承諾能力 (花蓮地院99重訴2：16歲為標準，舉輕§227、§241Ⅲ 明重§275)

5、SC 103台上1528

(1) 囑託須出自被害人直接、主動、明確、真摯之表示為限，應嚴格解釋

(2) 若已明示終止其同意或由客觀情狀得認默示終止其同意，即不能認有囑託

(3) 逾被害人明確指示之方式，難認受被害人囑託

6、競合：囑託或教唆殺直系血親尊親屬 ⇒ §272、§275Ⅰ 為法條競合 ⇒ §275Ⅰ 以免刑之過苛

7、既未遂：以死亡結果為斷

四、教唆、幫助自殺罪（§275Ⅱ）

1.教唆自殺

(1) 對原無自殺意思之人，教唆其生自殺之決意，因而實施自殺

(2) 決意須出於「自由且自我負責之決定」⇒ 對無自我決定意思之能力者（心神喪失、幼童）教唆自殺行為 ⇒ 殺人罪間接正犯

(3) 以暴力、恐嚇、威脅的方式強迫他人自殺 ⇒ 強迫被害人自殺以遂行殺人之目的 ⇒ 殺人罪間接正犯（SC 29上2014例）

(4) 錯誤之資訊誤導他人，誘發他人自殺，成立殺人間接正犯，ex：先生欺騙妻癌末，阻斷妻子求醫機會，妻子為免癌症自殺（澤：成立囑託§274Ⅱ）

2、幫助自殺

(1) 以積極助力幫助：對有自殺意思（具真摯性）之人，從旁予以助力，促成或便利其自殺（甘、田、王、SC 40民刑總會決議）

A、積極幫助：指示自殺之方法

B、物質上幫助：提供自殺工具、毒藥

C、精神上幫助：激勵自殺之勇氣（SC 50台上443例）

(2) 不加阻止（消極）

A、否定說（SC 32上187例、41台上118例、39台上305例、通、王、田）

a.阻止自殺固然道德高貴，但消極旁觀雖倫理上值得非難，仍不應以刑罰加以責難

b、極端 ex：尋死者站在高樓上欲跳樓，圍觀民眾若未阻止，均追究刑責，有過度擴張刑罰範圍之嫌

B、肯定說（甘）

(3) 對自殺者具保證人地位，消極不阻止 ⇒ 有無不純正不作為犯？

A、應貫徹原則，限提供積極助力

B、亦不應成立不作為殺人罪：應認主觀上係尊重自殺者之意思，無殺人之故意

C、醫師之義務衝突：若醫生選擇尊重病人自決權，不能因此就此認定醫生有殺人故意

D、Ger 通說：若病人不願接受治療，則醫師對病人已無保證人義務，亦無治療之義務，且不僅醫師，其餘醫護人員亦無保證人義務

3、主觀要件

(1) 出於使他人自殺之認識與意欲

(2) 無使人自殺之意思，僅出於一時玩笑或一時激動出言相激，對被害人自殺無法預見，則欠缺故意不成立（台南地院55年5月座談會）

(3) 故意傳達給被害人錯誤訊息，但無誘發他人自殺之意思，即使無意間引發他人自殺之動機，不成立教唆自殺罪

4、既、未遂

(1) 教唆、幫助行為開始說：性質上為獨立之正犯型態 ⇒ 教唆或幫助之危險已有促使或便利他人自殺之危險 ⇒ 不問目標生死或有無自殺行為（甘）

(2) 自殺後未死亡說：若教唆但對方無自殺行為，則非未遂（王、田、院字774解釋）

(3) 既遂 = 自殺 + 死亡結果發生

五、自殺結合他殺

Ger ⇒ 準共同正犯，但有實行支配 ⇒ 他殺 ⇒ §275Ⅰ 囑託殺人

澤：§275Ⅱ ⇒ 自殺之幫助

↳ ex：甲割腕自殺，已無力，求乙協助推刀，兩人協力將刀刺入甲

六、謀為同死（275Ⅳ）

1. 個人解除刑責事由（得免除其刑）：雙方當事人本質上係自殺，刑法不予處罰

2. 成立要件

(1) 雙方事前互相謀議或約定同死

(2) 同時具自殺意圖（SC 99台上7517）

(3) 出於自由意思與真意而約定同死

(4) 一方無自殺意思而以詐術提供訊息誘導他人約定同死，應認對死亡有優越認知與支配→成立殺人罪間接正犯（SC 56台上1767）

(5) 一方欠缺完整成熟之意思表示能力，自殺意思不具效力（SC 48台上380）

(6) 任一方當事人仍有隨時反悔之自由→被害人若無反悔可能則非自殺

└應嚴格限縮，死前皆有最終自由之自我決定及行為支配可能，若違反則可認為已有行為支配，適用§271

拾、過失致死罪（§276）

一、刪除§276Ⅱ業務過失致死罪

二、§276Ⅰ 2年以下 ⟶ §276 5年以下

三、行為主體：任何人

四、死亡結果出現：結果犯，過失不罰未遂（ex：甲超車不當，路人閃過無事）

五、客觀必要注意義務違反

1. §14Ⅰ：應注意，能注意，而不注意者，為過失

2. 行為人未違反注意義務，即使結果發生，仍不成立過失

3. 注意義務之內容

(1) 人類生活經驗累積之因果律或自然律推論認識所形成之規則 } 根據科學知識、邏輯推理或生活經驗之累積

(2) 注意規則須與法益受危害之預見可能性有內在關連性 } 如不遵守則通常會導致死亡結果發生

(3) ex：一般經驗法則、專業規範，專業領域中透過經驗實踐或專業知識之累積而形成避免危險結果出現之安全規則 ⇒ { 道路安全交通規則
醫療常規、建築成規、SOP…

4. 結果之客觀預見可能性

(1) 理論：行為人對結果之發生具可預見性才能調整或放棄行為或是提高安全措施以進行

(2) 應判斷對危險之發生有無預見之可能而疏未注意而發生危險（SC 91台上4857）

5. 履行注意義務之域及程度

(1) 同客觀預見可能性 ⇒ 採取平均人標準（若無統一標準，認定標準將分歧，形成判斷上之不安定性）

(2) 若對危險發生具特殊知識能力，或有高於一般人之認識，則應例外採個別化標準（提高注意義務，ex：醫師→平均醫師標準）

(3) 醫學常規之踐行，須考量院所資源及人力，不得以醫學中心之水準，據以認定診所醫師有無符合醫療常規（SC 95台上3884）

(4) SC 95台上3884：醫學中心＞區域醫院＞地區醫院＞一般診所；專科＞非專科

6. 因果关係/客观歸責

(1) Ger：條件因果理論+客观歸責

(2) TW实、JP：相当因果理論

(3) 現今实務实已夾雜客观歸責理論

(4) 特別考量「結果迴避可能性」，即倘若合乎注意义務，結果仍无可避免，应认違反注意义務与結果發生間不具相当因果关係（SC 89台上5241
SC 92台上4164）